Columbia Center on Sustainable Investment
A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL AND THE EARTH INSTITUTE, COLUMBIA UNIVERSITY

Columbia FDI Perspectives
哥大国际投资展望
No. 296　2021 年 1 月 25 日
主编: Karl P. Sauvant (Karl.Sauvant@law.columbia.edu)
执编: Riccardo Loschi (Riccardo.Loschi @columbia.edu)

行动空间：建构投资条约的灵活性，以履行气候变迁承诺*

Rachel Thrasher**

科学界和社会在气候变迁问题上立场明确。时间已经不多了，我们需要彻底的转变，以使经济生活与全球气候需要相适应。

世界各国出台了新的法律来支持可再生能源部门并鼓励能源转型，同时减少对化石燃料的依赖。与此同时，特别是发展中国家必须在能源转型与民众的发展需要之间取得平衡。这些新的法律(通常被称作“绿色产业政策”)也与外国投资者有关，这促使他们向绿色能源注资，同时也有助于当地经济的多元化。世界银行(WB)、国际货币基金组织(IMF)以及其他国际机构虽然并不一致，但是已经开始通过优先考虑气候友好型发展项目的制度安排来支持这些法律。

然而，国际投资机制往往落后于科学界、社会甚至国际金融机构。绝大多数投资条约仅关注于投资保护，而对投资的影响不予置评。因此，这些条约阻碍了促进气候友好型(或阻止气候有害型)投资的措施。新的条约表述仅略微增加了政策灵活性。一些新的条约通过重申各项多边气候协议中的承诺来应对气候变迁(例如巴西-智利, 厄瓜多尔-欧洲自由贸易联盟(EFTA))。这些条款虽然展现出各国政府鼓舞人心的发展方向，但是一般不要求缔约方彼此对这些承诺负责。其他新的条约包含通过投资便利化条款应对气候变迁难题的投资条款——旨在增加对环境友好型商品和劳务的投资(例如欧盟-日本, 欧盟-新加坡)。然而，投资便利化的表述尚不完整，仍然使自由化的投资体制凌驾于政府对关键部门的监管权之上。还有一些条约保留了取消某些投资激励措施的权

利，即使投资者的利益会因此受到不利影响(例如全面经济贸易协定(CETA)、欧盟-越南)，但是这些条约的影响尚不明确，而且常常(自相矛盾地)避免直接提及气候变迁。

尽管最近的条约调整了传统投资承诺的范围，但是当前机制很大程度上仍制约着政策制定者制定气候变迁政策时的行为。三种国际案例阐明了各国为此面临的法律障碍:

- 如果国家通过自制率要求，将投资激励与国内可再生能源产业建设挂钩，WTO 会认为这违反了 WTO 规则(例如加拿大-强制性关税(FIT), 印度-太阳能, 美国-可再生能源).
- 各国推进可再生能源投资激励项目(而不是遵守条约)时，如果激励措施过于顺利、过于迅速，政府无法同时满足投资者和国内消费者的需求，就会发生投资者-国家诉讼(例如 *Foresight v. Spain*, *Antaris v. Czech Republic*).
- 各国试图逐步淘汰传统能源(如煤炭)时，会被这些公司指控违反投资条约义务(横加公司、西摩兰公司)[1].

现实导致一些国家完全退出投资者-国家执行机制和投资条约。然而，并非所有国家都有这样做的政治权力或意愿。对这些国家而言，需要另辟蹊径。条约应该允许各国采取气候适应性政策，以促进绿色工业发展，阻止化石燃料投资等气候“公敌”。
恰如其分的解决方案将朝着这一目标迈出关键一步。首先，各国可以暂时同意为促进可再生能源行业(长期)全球竞争的产业政策“亮绿灯”[2]。这一方案仿效了 WTO 逐步取消补贴的规则，使各国得以提供国内支持，落实产业政策，鼓励可再生能源生产，进而建构当地可再生能源部门，使可再生能源长远来看更廉价易得。

此外，条约应区分可再生能源行业和化石燃料行业的政策和保护措施。这种做法借鉴了《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》中的渔业补贴规则[3]，要求各国区别对待化石燃料投资，取消补贴形式的传统支持，防止各国通过产业政策发展本国化石燃料部门。如果与允许对可再生能源提供补贴和其他支持的特许政策相结合，这些条款将激励化石燃料公司(以及其他公司)同样投资于能源转型过程[4]。

实现结构性改变任重而道远，我们必须即刻开始调整经济和气候目标。各国政府必须有行动空间并灵活应对民众的需要。新的条约必须体现这一现实，想方设法使各国能够评估外国直接投资对其经济的短期和长期影响。

（南开大学国经所郭子枫翻译）

---

[*] ***哥大国际投资展望*(Colombia FDI Perspectives)是一个公开辩论的论坛。作者所表达的观点并不代表 CCSI 或哥伦比亚大学或我们的合作伙伴与支持者的观点。*哥大国际投资展望*(ISSN 2158-3579)是一个同行评审系列。**

[**] Rachel Thrasher (rthrash@bu.edu)是波士顿大学全球发展政策中心的研究员和贸易政策协调员。
作者希望感谢 Kevin Gallagher, Bill Kring 对本文早期草稿的评论，以及 Jesse Coleman, Nikos Lavranos, Peter Muchlinski 的同行评审。这篇*展望基于* Lisa Sachs, Lise Johnson, Jesse Coleman 编纂，*《国际投资法律与政策年鉴》*第 15 章和第 23 章 (牛津大学出版社(OUP), 2018)。

[1] Lisa Sachs, Ella Merrill and Lise Johnson, "Environmental injustice: How treaties undermine the right to a healthy environment," *Bilaterals*, Nov. 13, 2019.

[2] Thijs Van de Graaf1 and Harro van Asselt, "Introduction to the special issue: Energy subsidies at the intersection of climate, energy, and trade governance," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, vol. 17 (2017), p. 322.

[3] Margaret A. Young, "Energy transitions and trade law: Lessons from the reform of fisheries subsidies," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, vol. 17 (2017), p. 382.

[4] Sarah Keah-Bright and Steivan Defilla, "Energy Charter Treaty should end protection for fossil fuels," *Energy Post*, Mar. 20, 2019.

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印:"Rachel Thrasher, 《行动空间：建构投资条约的灵活性，以履行气候变迁承诺》，哥大国际投资展望，No.296, 2021 年 1 月 25 日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转载(www.ccsi.columbia.edu)。"请将复印件发送至哥伦比亚可持续投资中心 ccsi@law.columbia.edu。

获取更多信息，包括关于提交给*展望*的信息，请联系:哥伦比亚可持续投资中心，Riccardo Loschi, riccardo.loschi@columbia.edu.

哥伦比亚大学可持续投资中心(CCSI)是哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学地球研究所的联合中心，是一个领先的应用研究中心和论坛，致力于可持续国际投资的研究、实践和讨论。我们的任务是制定和传播切实可行的办法和解决办法，并分析当前的政策性问题，以便最大限度地发挥国际投资对可持续发展的影响。该中心通过跨学科研究、咨询项目、多方利益相关者对话、教育项目以及资源和工具的开发来承担其使命。获取更多信息，请访问我们的网站 http://www.ccsi.columbia.edu.

最新的*哥大国际投资展望*

- No. 295, Stefanie Schacherer, 《通过国际投资协定促进投资：以 RCEP 为例》 2021 年 1 月 11 日
- No. 294, Federico Ortino, 《缓解投资条约保护的混乱》 2020 年 12 月 28 日
- No. 293, Crina Baltag, 《投资：从促进与保护到监管》 2020 年 12 月 14 日
- No. 292, Khalil Hamdani, 《投资便利化框架的发展层面》 2020 年 11 月 30 日
- No. 291, Rudolf Adlung, Pierre Sauvé, Sherry Stephenson,《投资便利化与 GATS: 重叠有何影响?》 2020 年 11 月 16 日

所有先前的*哥大国际投资展望*均载于： http://ccsi.columbia.edu/publications/columbia-fdi-perspectives/.